

1501122-18.2022.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... foi preso de novo. Saiu em 2017 e foi preso no tráfico e associação. Foi absolvido e foi forjado em outro tráfico, tirou quatro anos dessa situação. Recebeu indulto do dia das mães, mas não voltou pois estava sendo ameaçado na cadeia e na rua. Fernando é seu irmão e deu esse nome quando da apreensão dos veículos, foi três semanas antes desse roubo. Pratica airsoft e comprou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501122-18.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501122-18.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2100639/2022 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 24262216 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2100639 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2100639 - 04º D.P. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO CARDOSO DOS SANTOS

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

FLÁVIO CARDOSO DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, caput, c.c artigo 61, inciso II, alínea "h", na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, e no artigo 307, também do Código Penal, em concurso material de delitos.

Consta do incluso inquérito policial que, em 12 de abril de 2022, por volta das 08h38min, no cruzamento da Rua Pedro Elias com Rua Francisco Bonim, Jardim Vista Alegre, nesta cidade e comarca de Limeira, o acusado tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, coisa alheia móvel, a saber, uma bolsa contendo objetos e valores, pertencente à vítima Zulmira Barbosa, maior de 60 (sessenta) anos, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta, ainda, que, após os fatos acima narrados, na ocasião da prisão em flagrante, o denunciado atribuiu-se, em proveito próprio, falsa identidade para obter vantagem.

Segundo apurado, na primeira ocasião acima referida, o denunciado, apoderado de um simulacro de arma de fogo e imbuído na intenção de praticar o roubo, dirigiu-se ao sítio do evento onde abordou a vítima na via pública e, encostando o aludido simulacro em sua barriga, puxou a bolsa que a vítima trazia a tira colo, objetivando a subtração.

Ocorre que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando receberam informação dando conta que um indivíduo portava arma de fogo nas imediações. Ato contínuo, os agentes públicos encetaram diligências e avistaram o denunciado subjugando a vítima no local dos fatos e realizaram a abordagem.

Em seguida, já configurando a segunda ocasião acima narrada, no momento da prisão em flagrante, o denunciado apresentou-se aos policiais com o nome Fernando Cardoso dos Santos, com o intuito de obter vantagem em proveito próprio, consistente na obtenção de benefícios processuais e obstrução das investigações sobre o roubo em análise, sendo depois descoberta sua verdadeira identidade.

Consigna-se, ainda, que o crime de roubo visado pelo denunciado somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista que fora percebido pelos agentes públicos, os quais o detiveram antes da consumação do delito.

A denúncia foi recebida em 28 de abril de 2022 (fls. 108/110).

O réu foi citado (fls. 125) e apresentou defesa escrita (fls. 130/131).

Foi mantido o despacho de recebimento da denúncia (fls. 134/135).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e testemunhas arroladas, com o interrogatório do réu ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

Alegações finais orais do Ministério Público (mídia) e alegações finais escritas da Defensoria Pública (fls. 164/172).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Aprecio a preliminar levantada em sede de memoriais defensivos.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de oitiva de testemunhas referidas, inviável o acolhimento, uma vez que se mostra, com a devida vênia, impertinente e protelatória.

O §1º do artigo 209 do Código de Processo Penal faculta ao magistrado em proceder a oitiva de testemunhas referidas quando lhe “parecer conveniente”.

Não bastasse, cumpre salientar que não surgiu fato novo para que a defesa buscasse o depoimento das testemunhas Jaqueline e Marinês na segunda audiência (fls. 160), na medida em que já havia ocorrido audiência anterior nos autos (fls. 151 – conversa privativa entre defensora e acusado), não tendo sido arroladas as testemunhas em sede de resposta à acusação (fls. 130/131).

Desse modo, se a defesa não arrolou as testemunhas em momento apropriado é porque não tinha interesse em sua oitiva, não podendo exigir que o magistrado o faça quando não surgiu, repita-se, fato novo que exigisse sua participação nos autos, não podendo a regra do artigo 209, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, ser

empregada como sucedâneo de arrolamento intempestivo de testemunhas.

Aplica-se ao caso o disposto no artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal: "As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias".

É sabido que o indeferimento de determinada diligência probatória requerida pela defesa ou pela própria acusação não se qualifica, só por si, como medida caracterizadora de cerceamento da defesa, desde que encontre suporte em decisão adequadamente motivada (art. 400, §1º, do Código de Processo Penal).

O julgador exerce, nessa matéria, irrecusável competência discricionária, que lhe permite, a partir de uma avaliação pessoal quanto à conveniência ou necessidade da medida, ordenar, ou não, sempre em decisão fundamentada, a adoção dessa providência de caráter instrutório.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DILIGÊNCIA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repete impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual" (HC 106.734, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O acolhimento da pretensão defensiva - no tocante à insuficiência de provas para a condenação - demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento". (STF, RHC 150703 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 04-06-2019 PUBLIC 05-06-2019).

"Habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Crimes de estupro e atentado violento ao pudor. Artigos 213 e 214 do Código Penal. Pedido de produção de prova formulado pela defesa. Requerimento motivadamente indeferido. Possibilidade. Alegado cerceamento de defesa não evidenciado. Precedentes. Ordem denegada. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que "não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repete impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual" (HC nº 106.734/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/5/11). 2. Na espécie o pedido de provas requeridas pela defesa foi motivadamente indeferido pelo juízo de piso por entender serem elas meramente procrastinatórias. 3. Nesse contexto, a presença de justificativa para a negativa de produção das provas requeridas pela defesa é o que basta para se denegar a ordem, uma vez que, na linha de precedentes, a via do habeas corpus não abre passagem para se aferir o acerto ou desacerto daquela decisão. 4. Ordem denegada". (HC 108961, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012).

Se assim é, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de oitiva de testemunhas referidas, se foram consideradas desnecessárias pelo órgão julgador, a quem compete a avaliação da necessidade ou conveniência do procedimento então proposto, daí porque rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Não há outras preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 16), laudo pericial (fls. 122/123), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Em juízo, o acusado disse que tem 32 anos. Estava desempregado. A vítima é vizinha da sua casa. Estava evadido do sistema prisional. Não voltou pois temia pela sua vida. Sofreu represália na rua por conta de dívidas. Umas pessoas guardaram carros na sua casa. Foi para a delegacia. Deu nome falso ao delegado e conseguiu sair do distrito policial. Decorrido duas semanas, coleciona airsoft, foi comprar essa arma. Na esquina de baixo encontrou a vítima. Já fez vários trabalhos a ela de limpeza. Houve uma desavença com sua mulher a respeito do roubo de um ventilador. Houve rixa entre as mulheres. Subia a avenida e esse airsoft estava na sua bolsa junto com um colete. Passou um rapaz de motocicleta e ele o viu colocando esses objetos na bolsa. Avistou a vítima e foi tirar satisfação dela ter ido prestar queixa contra sua mulher. A viatura policial parou e nem notou a presença dos policiais. Falou que estava com a arma na mochila. É uma réplica de 380. Conhecia a ofendida. Foi recapturado pois era evadido do sistema prisional. Nessa vez não deu o nome falso. Sempre procurava ajuda da vítima. Em 2013 foi forjado em homicídio, conseguiu provar a inocência. Em 2015 respondeu por furto qualificado, foi preso de novo. Saiu em 2017 e foi preso no tráfico e associação. Foi absolvido e foi forjado em outro tráfico, tirou quatro anos dessa situação. Recebeu indulto do dia das mães, mas não voltou pois estava sendo ameaçado na cadeia e na rua. Fernando é seu irmão e deu esse nome quando da apreensão dos veículos, foi três semanas antes desse roubo. Pratica airsoft e comprou essa arma. Nesse dia tinha acabado de comprar o objeto e voltava para sua casa. Comprou a arma por volta das sete e meia da manhã, o comércio fica aberto nesse horário. Não mostrou a nota fiscal porque os policiais não quiseram saber de nada. É a primeira arma que tinha. Os policiais falaram que o objeto estava na sua cintura, mas isso não é verdade. Estava sendo monitorado pelos guardas. Não contente de ser foragido, os policiais forjaram a sua prisão. Ficou sabendo que os policiais quiseram colocar drogas na sua casa para prender sua esposa. Não iria roubar uma senhora que sempre o ajudou. Acredita que a vítima tem 60 a 70 anos, ela anda de bengala e tem alzheimer. Havia uma rixa entre sua esposa e a vítima. A ofendida teve vários surtos psicóticos. Não tirou a arma da bolsa, só colocou o objeto quando saiu da loja. O rapaz da motocicleta o viu tirando o objeto, mas colocou na bolsa. A pessoa de motocicleta parou e ficou olhando na sua direção. Foi seguido por esse motociclista. Comprou o objeto em frente à Casa de Pesca Imperial localizada na Rua Pedro Elias. Não sabe o nome do vendedor. Não soube explicar o fato do comércio abrir apenas as 9 horas da manhã e de ter sido atendido em horário anterior. Pagou duzentos reais em dinheiro. Marinês teria visto pois ela tinha acabado de sair para abrir a loja. Negou ter ameaçado a vítima, muito menos retirado o objeto airsoft e colocado na cintura, só queria saber o que a ofendida tem contra sua esposa (mídia).

Sua versão não convence.

Vejamos o teor da prova oral, contrária aos interesses do réu.

A vítima Zulmira Barbosa disse que nasceu no ano de 1946. Não reconheceu o acusado em audiência. Mora na Rua Francisco Bonim. Confirmou que o assaltante tentou pegar sua bolsa e estava com uma arma que não era verdadeira. Segurou forte a bolsa, ele não conseguiu furtar. Um carro policial parou e deu suporte. O policial disse que o acusado era procurado. Conhecia o réu, ele é amante da sua vizinha de fundo e lá morava. Não teve qualquer briga com o réu. Só ela foi conduzida ao distrito policial. Saiu da Rua Pedro Elias e acabou de virar a esquina, o denunciado chegou e puxou a sua bolsa. Nunca teve nada com ele. O acusado encostou algo nela, não era

arma. Ficou acuada na esquina. Nunca discutiu com o réu. Viu a fotografia de fls. 41. Não tem filhos e mora sozinha. Está com problemas de saúde e usa bengala. Toma medicação. Entendeu o dia errado, por isso não veio na audiência anterior. Faz acompanhamento médico em postos de saúde. Não tem alzheimer. Jaqueline é a sua vizinha e teve desentendimento com ela depois desse roubo. O namorado de Jaqueline foi tirar satisfação, mas tinha certeza do crime. Conhece Marinês e ela mora na rua da sua casa. Alguns vizinhos querem acobertar o que aconteceu, outros não acobertaram. Chegaram a falar que Jaqueline anda com pessoas perigosas. Marinês pediu a ela para abafar o caso, que poderia sobrar para ela. O namorado de Jaqueline nunca trabalhou na sua casa (mídia).

Como é sabido, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima, que nenhum interesse tem no deslinde da demanda, é de suma importância, pois narrando o proceder de estranhos, o único interesse delas é apontar os verdadeiros culpados e recuperar eventuais bens perdidos e não acusar inocentes.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"Art. 157, par. 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal - Autoria e materialidade delitiva demonstradas. Prova - Palavras da vítima e de servidores públicos - Credibilidade - Inexistência de motivos para acusarem injustamente o réu. Pena e regime prisional corretamente fixados. Recurso não provido." (TJSP; Apelação Criminal 1505139-53.2020.8.26.0228; Relator (a): Machado de Andrade; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/07/2021; Data de Registro: 02/07/2021).

"ROUBO QUALIFICADO - EMPREGO DE ARMA e CONCURSO DE AGENTES. Fragilidade da prova. Não comprovada. Negativa de autoria que não encontra consonância nas demais provas. No cotejo entre a fala da acusada, isento de compromisso e de produzir prova contra si próprio e da vítima que pode responder por suas afirmações em faltando com a verdade, de se valorar a palavra destes últimos. Regime fechado. Mantido. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP; Apelação Criminal 0004409-78.2009.8.26.0624; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/11/2016; Data de Registro: 24/11/2016).

"Roubo majorado tentado. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras da vítima e das testemunhas. Versão do réu inverossímil. Elementos colhidos na fase administrativa que podem ser valorados quando confirmados por outros submetidos ao contraditório. Condenação acertada. Regime fechado que se impõe. Gravidade do delito e circunstâncias fáticas, notadamente a presença de múltiplos agentes, o enfrentamento físico com a vítima que o justificam e a recaptura do réu em flagrante pelo mesmo delito algum tempo depois. Recurso da defesa improvido. Recurso da acusação provido." (TJSP; Apelação Criminal 0000271-21.2014.8.26.0292; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacareí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/10/2016; Data de Registro: 01/11/2016).

O policial militar Marcelo Machado de Souza disse que fazia ronda escolar quando um motoboy contou ter visto uma pessoa suspeita retirando o que seria um armamento e colocando na região das costas. Características dessa pessoa foram repassadas. Fizeram patrulhamento e logo em seguida viram o réu, com as mesmas características informadas, e uma senhora no canto. Visualizaram ele estava em cima dessa idosa. Fizeram a abordagem. Indagado, ele disse que a arma encontrada em seu poder era de airsoft. Em seguida, ele deu o nome do seu irmão. A senhora foi entrevistada e disse que foi encostada na parede, o réu pediu a bolsa mostrando aquela arma apreendida. A senhora viu o armamento utilizado. O acusado não chegou a pegar a

bolsa porque ela se recusou a entregar, eles chegaram rapidamente. Prenderam o acusado em flagrante delito. Outra viatura chegou e os policiais militares avisaram que já tinham detido o réu semanas anteriores por envolvimento em receptação. Uma pessoa chegou e disse que o nome verdadeiro do acusado era Flávio. Só depois ele confessou que era foragido do sistema prisional e usou o nome do seu parente para não ser preso (mídia).

O policial militar Ricardo Júnior Pinheiro da Silva contou que são da patrulha da ronda escolar. Faziam ronda quando foi irradiado via Copom que uma pessoa sacou o que seria uma arma e colocou nas costas. Foram fazer averiguação da denúncia. O motoqueiro que ligou para a Polícia Militar passou as características e vestes, contando onde a pessoa estaria. Na esquina em questão, viram o acusado com uma senhora próxima a ele. Fizeram a abordagem. O réu disse que conhecia a vítima. Apreenderam uma arma em seu poder. O acusado passou o nome de Fernando para esconder o passado criminoso. As fotografias não batiam. Foi constatado que o nome dele era Flávio. Deram voz de prisão. No momento que chegaram a arma estava na região das costas do acusado. A senhora disse que o roubador tentou levar a bolsa colocando uma arma na região da barriga dela. Ficharam ele como Fernando, mas um popular disse que ele não tinha esse nome, daí porque passaram a averiguar, as fotografias não batiam. Descobriram que Fernando era o irmão dele. Só depois ele contou que estava foragido do sistema prisional e usava o nome do irmão. Em nenhum momento a senhora disse que o conhecia, mas ele falou que ambos se conheciam. A senhora mora perto do local dos fatos. A vítima é uma pessoa idosa e narrou que furtos em dias anteriores ocorreram na sua casa, ela tentou registrar queixa. Não conhecia o acusado até então. Uma equipe encostou no apoio e disse que já havia detido o réu em data anterior. A arma era de airsoft, com peso de metal, é bem semelhante a uma arma comum. A ofendida contou a eles que o réu chegou colocando a arma na sua cintura e pedindo a sua bolsa (mídia).

Ressalto que o depoimento de policiais militares neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos policiais, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente o réu.

Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Passo a analisar os delitos separadamente.

Artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Pelo teor da prova oral colhida, o acusado, em poder de um simulacro de arma de fogo, abordou a vítima na via pública e, encostando o aludido simulacro em sua barriga, puxou a bolsa que a vítima trazia buscando a subtração.

Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando receberam informações de que um indivíduo portava arma de fogo nas mediações. Na sequência, os agentes policiais avistaram o réu subjugando a vítima no local dos fatos e realizaram a abordagem, havendo prisão em flagrante.

O delito de roubo somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, haja vista que fora percebido pelos agentes públicos, os quais o detiveram antes da consumação do delito.

O depoimento da ofendida foi firme no sentido de descrever como se deu o delito de roubo em juízo, apesar de não ter reconhecido o réu em audiência em razão da sua idade avançada e estado de saúde comprometido. O reconhecimento extrajudicial, todavia, foi corroborado pelo relato dos dois policiais militares ouvidos em audiência, não sendo prova isolada, havendo prisão em flagrante e apreensão de simulacro de arma em poder de agente.

No mais, observo que não foram ouvidas testemunhas de defesa que amparassem a alegação de falta de provas, devendo prevalecer o firme relato da vítima e das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.

A respeito do reconhecimento pessoal e da sua legalidade quando corroborado por outras provas, assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 226 E 564, IV, DO CPP; 33, §§ 2º E 3º, E 70 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), não foi apenas o reconhecimento pessoal realizado pela vítima que embasou a denúncia ofertada contra o paciente pela suposta prática do crime de roubo; ao contrário, o inquérito policial mencionou, ainda, a situação em que foram localizados os suspeitos, pouco tempo após a subtração do veículo, e os depoimentos dos policiais que participaram da diligência (...) 5. Agravo regimental não provido”. (STJ, AgRg no AREsp 1572641/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDADA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que “a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado

por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento da vítima, verifica-se prova testemunhal do policial civil Miguel, bem assim todos os indícios inferidos das circunstâncias corpo de delito que apontam para a autoria do recorrente. Há, pois, elementos probatórios suficientes para produzir cognição com profundidade adequada para alcançar o juízo condenatório. 5. Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no HC 612.588/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Da mesma forma, há julgados oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) que confirmam a validade e constitucionalidade do reconhecimento pessoal como prova apta a sustentar uma sentença penal condenatória, ainda mais quando corrobora por outras evidências nos autos, não sendo caso de desentranhamento, muito menos de ilicitude da prova, na esteira da jurisprudência que segue:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. (...) 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento". (STF, HC 207000 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 10-11-2021 PUBLIC 11-11-2021).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. (...) 3. Além de facultativa a realização de reconhecimento pessoal, na espécie, a aludida diligência realizada em fase inquisitorial não foi a única prova produzida para efeito da condenação do ora Agravante. Precedentes. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento." (STF, HC 158659 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 14-11-2018 PUBLIC 16-11-2018).

Respeitado o entendimento da combativa defesa, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e a autoria do crime de roubo tentado imputado.

Houve grave ameaça pelo potencial intimidatório utilizado pelo acusado na prática do crime (simulação de estar armado e abordagem de pessoa do sexo feminino maior de sessenta anos). A respeito da grave ameaça no delito de roubo, trago à baila os ensinamentos de Cleber Masson:

"A grave ameaça é também chamada de violência moral ou de vis compulsiva. Consiste na promessa de mal grave, iminente e verossímil, isto é, passível de realização. Pode-se exteriorizar por palavras, gestos, símbolos, utilização de objetos em geral ou qualquer outro meio idôneo a revelar a intenção do agente de subjugar a vítima. Seu potencial intimidatório deve ser aferido no caso concreto, baseado nas circunstâncias ligadas à prática do crime, tais como o sexo e as condições físicas do agente e da vítima, o local e o horário do delito, entre outras (...) A grave ameaça, contudo, deve estar indispensavelmente ligada a uma subtração patrimonial. Do mesmo modo que não se podem exigir atitudes heroicas das pessoas, é também vedado concluir automaticamente pelo roubo nas atitudes das pessoas covardes (MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado: parte especial - vol. 2. 6. ed. Rio



de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014).

Não há que se cogitar em consumação do delito. O roubo em questão não se consumou, porquanto o réu não logrou inverter a posse sobre os bens que pretendia furtar. Como é sabido, o roubo se consuma no momento da inversão da posse, cessada a violência ou grave ameaça empregadas.

Tal entendimento se encontra consubstanciado na Súmula nº 582 do STJ:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Não se acolhem também as versões de crime impossível ou desistência voluntária.

O crime impossível somente se configura quando, pela ineficácia absoluta do meio ou impropriedade do objeto, não se concretiza o resultado lesivo. Mas, para tanto, necessário que o meio empregado seja ineficaz ou o objeto seja impróprio, o que não foi o caso dos autos. Mesmo frustrado o proveito patrimonial esperado pelo roubador, houve crime de roubo tentado no caso em tela, não havendo absoluta ineficácia do meio ou do objeto.

A desistência voluntária, o arrependimento eficaz e a tentativa apresentam em comum características de ordem objetiva e de conotação subjetiva. Nos três institutos, ocorre uma ação realizada pelo agente, cuja vontade, de acordo com o plano previamente esboçado, está dirigida à produção de um resultado ilícito que não chegou, contudo, a consumir-se. A partir daí, no entanto, os institutos se distinguem. A consumação não é alcançada por razões diversas: na tentativa, por circunstâncias alheias à vontade do agente; na desistência e no arrependimento eficaz, por manifestação de vontade do agente.

No caso, o que frustrou a ação do réu é que os agentes públicos efetuaram a abordagem e o detiveram antes da consumação do delito. Veja-se que o delito de roubo não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, e não por manifestação do acusado.

Não assiste razão a tese de atipicidade da conduta por não ter o agente ultrapassado a fase dos atos preparatórios. Embora o réu não tenha subtraído os bens, restou bem demonstrado que praticou os atos executórios do delito para efetuar a subtração ilícita de bem alheio que lhe interessava, mediante grave ameaça exercida com simulação de estar armado.

Portanto, a única possibilidade possível para correta adequação entre conduta e norma penal é a prática do crime de roubo simples (artigo 157, caput, do Código Penal ).

A versão apresentada pelo réu não pode ser levada em consideração na sua integralidade, já que em conflito com as demais provas colhidas, não havendo motivos para se desconsiderar a palavra da vítima, não se cogitando em desclassificação para o crime previsto no artigo 345 do Código Penal.

Fosse o acusado realmente inocente, certamente ele teria envidado todos os esforços possíveis e lícitos para satisfazer a sua pretensão. Sua versão não ampara o acolhimento da tese de desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (artigo 345 do CP).

Saliento que a embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a responsabilidade penal do acusado. Ainda que estivesse completamente embriagado e feito uso de

drogas, o uso de álcool e de entorpecentes foi espontâneo, com o que deve ser responsabilizado e não afastado o seu dolo em razão da adoção em nosso ordenamento jurídico da teoria *actio libera in causa*.

Recorde-se a advertência de Fernando Capez ao acentuar a seguinte lição:

"A embriaguez não accidental jamais exclui a imputabilidade do agente, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta. Isso porque ele, no momento em que ingeria a substância, era livre para decidir se devia ou não fazer. A conduta, mesmo quando praticada em estado de embriaguez completa, originou-se de um ato de livre arbítrio do sujeito, que optou por ingerir a substância quando tinha a possibilidade de não o fazer. A ação foi livre na sua causa, devendo o agente, por essa razão, ser responsabilizado". (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, v. 1. 23. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

A embriaguez só é proveniente de caso fortuito quando o sujeito desconhece o efeito inebriante da substância que ingere. Em sendo voluntária, não há falar-se em exclusão da responsabilidade penal do réu.

Artigo 307 do Código Penal.

Quanto ao crime de utilização de falsa identidade praticado pelo acusado, entendo que também é caso de procedência.

Muito embora exista entendimento no sentido de que o fato descrito na denúncia não constitui crime em razão de ter o réu direito de não produzir prova contra si mesmo (*nemo tenetur se detegere*), sendo permitida essa forma de autodefesa, nos termos do art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, o entendimento hoje dominante é no sentido de que é permitido apenas ao acusado que permaneça calado e não que minta em relação à sua qualificação.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou recurso extraordinário, no qual foi reconhecida repercussão geral, julgando caracterizado o delito em tais hipóteses:

"EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes." (STF, RE 640139 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-00885 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 668-674 RTJ VOL-00233-01 PP-00311).

O Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 522, com o seguinte teor: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".

Tratando-se o delito do art. 307 do CP de crime formal, é desnecessária a consumação de obtenção da vantagem ilícita própria ou de outrem, ou mesmo a ocorrência de danos a terceiros.

A partir das provas produzidas e juntadas aos autos, não há dúvidas de que o acusado, ao atribuir para si a falsa identidade de Fernando Cardoso dos Santos, com o intento de se beneficiar, evitando-se que seus antecedentes criminais fossem revelados, praticou o delito previsto no art. 307 do CP, sendo de rigor a

condenação nesse específico crime.

Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para o seu ato, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Na primeira fase, atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes (fls. 46/55 - autos nº 0004273-23.2009.8.26.0320, 0011122-45.2008.8.26.0320, 0014311-94.2009.8.26.0320, 0020920-25.2011.8.26.0320 e 0023009-84.2012.8.26.0320), de modo que fixo a pena-base acima do mínimo legal (1/6), ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador (cf. STJ, HC 515.516/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020; EDcl no AgRg no Resp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020 AgRg no AREsp 648.374/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016; AgRg no HC 354.093/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016; AgRg no AREsp 924.453/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pacificou o entendimento no Tema 150, no julgamento do RE 593818, ao fixar a tese de que "não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reconhecendo, portanto, o uso de condenações de definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e não atingidas pelo período depurador da reincidência, como maus antecedentes para fins de fixação da pena-base.

Na segunda fase o réu é multirreincidente (fls. 46/55 autos nº 0006985-73.2015.8.26.0320, 0010101-19.2017.8.26.0320 e 0015054-94.2015.8.26.0320) e cometeu crime contra pessoa idosa. Desta forma, elevo a pena em 1/5, totalizando 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, com pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Não se conhece qualquer declaração de inconstitucionalidade quanto à reincidência por parte dos tribunais superiores, muito menos a necessidade de certidões cartorárias específicas para esse fim, anotando-se que a folha de antecedentes se presta para tanto.

A reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. Nada impede o juiz de valorar negativamente na fase de fixação da pena a escolha do agente em voltar a delinquir, o que confere maior juízo de censura em relação a nova conduta delitiva praticada, não se tratando de nova punição do crime pretérito. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):

"AGRAVANTE - REINCIDÊNCIA - CONSTITUCIONALIDADE - Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência". (STF, RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013).

Na terceira fase, como o crime de roubo não se consumou, reconheço a presença da causa de diminuição da tentativa. O critério a ser considerado para fixação do

quantum da fração referente à tentativa é o iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais próximo o agente houver chegado à consumação, menor será a diminuição na reprimenda.

Assim, demonstrado que o acusado percorreu parte do iter criminis do delito, reduzo as penas em metade (1/2), fixando-as em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa, a qual torno definitiva.

Fixo a pena de multa no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do réu.

Artigo 307 do Código Penal.

Na primeira fase, atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes, de modo que fixo a pena-base acima do mínimo legal (1/6), ou seja, em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, o réu é multirreincidente. Dessa forma, elevo a pena em 1/6, totalizando 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Na terceira fase, ausentes quaisquer causas de aumento ou diminuição, mantenho a pena acima fixada.

Presente o concurso material de delitos (crimes de roubo e falsa identidade), na forma do artigo 69 do CP, somo todas as penas para totalizar 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa pelo crime de roubo e mais 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção pelo delito de falsa identidade.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, sendo o acusado portador de maus antecedentes e reincidente, com abordagem de pessoa do sexo feminino maior de 60 (sessenta) anos, deverá iniciar o cumprimento da pena do crime patrimonial em regime inicial fechado.

O delito de roubo, por toda a violência e agressividade que lhe é intrínseca, não comporta reprimenda leve, que traduziria sensação de impunidade, estimulando a recidiva. Ademais, o acusado é portador de maus antecedentes, o que demonstra personalidade voltada a prática de delitos.

Em que pese o quantum da pena aplicada, a fixação do regime inicial semiaberto não é ajustada à situação dos autos, uma vez que, mesmo não tendo restado consumado o crime de roubo, o fato é que a conduta se revestiu de maior gravidade, ao envolver grave ameaça, mediante simulação de faca, a vítima do sexo feminino, e também por se tratar de acusado portador de maus antecedentes.

Nos termos do art. 44 do CP, tendo sido o crime cometido mediante grave ameaça, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Quanto ao crime de falsa identidade (apenado com detenção), o regime inicial será o semiaberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar FLÁVIO CARDOSO DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 06 (seis) dias-multa, no valor mínimo, como incurso no artigo 157, caput, c.c artigo 61, inciso II, alínea "h" na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como ao cumprimento da pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, em

regime inicial semiaberto, como incurso no art. 307 do Código Penal, na forma do art. 69, caput, do Código Penal (concurso material).

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante esse processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram a prisão, em especial, a necessidade de garantir a ordem pública, ante as nefastas consequências de crimes contra o patrimônio para a sociedade em geral e a probabilidade concreta de solto voltar a praticar a atividade criminosa, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra recolhido, anotando-se que é reincidente e portador de maus antecedentes.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, porque tal não foi objeto de discussão nos autos e, portanto, prejudicada ficou a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa neste ponto, de tal sorte que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, contraria o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora concedida.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Limeira, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA